

学生A、B及びCは、承継的共同正犯に関する次の【事例】について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内にはそれぞれ異なるものが入る。

【事例】

先行者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後、後行者が、共謀加担した上、被害者が負傷して抵抗が困難になった状態を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思で、更に暴行を加えて被害者の同傷害を相当程度重篤化させた。

【会話】

学生A. 私は、承継的共同正犯については(①)と考え、その成立を(②)します。

学生B. Aさんの見解では、詐欺罪で金銭受領のみに関与した後行者が不可罰となってしまうませんか。私は、承継的共同正犯については(③)と考え、その成立を(④)すべきだと考えます。

学生C. 私も、承継的共同正犯の成立を(④)すべきだと思います。私は、(⑤)と考え、この【事例】については、後行者に(⑥)の共同正犯の成立を認めます。

学生B. Cさんの見解では、共謀加担前の結果に対する因果性の欠如を埋め合わせることができないのではないのでしょうか。私は、Cさんが承継的共同正犯の成立根拠とする事情は、判例が言うように(⑦)と評価すべきであって、(⑥)の責任を問う理由とはいえないと考えます。私は、Cさんと異なり、この【事例】の後行者に(⑧)の共同正犯の成立が認められると考えます。

【語句群】

- a. 後行者が関与する時点において、なお先行者が実現しようとしている結果については因果性を有することが可能である
- b. 後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、それが一定の構成要件に該当する限度で共同正犯が成立する
- c. 先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべき
- d. 後行者が暴行を行った動機ないし契機にすぎない
- e. 自己の犯罪遂行の手段である
- f. 全面的に肯定
- g. 限定的に肯定
- h. 全面的に否定
- i. 共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪
- j. 共謀加担後の傷害結果の発生に寄与した部分についての傷害罪

1. ①a ④f ⑦d
2. ①b ③a ⑦e
3. ②h ⑤a ⑥i
4. ③c ④g ⑧i
5. ⑤c ⑥i ⑧j

№157	承継的共同正犯	正答率 47%
R6-9	正解 5	

()には順に、「①=b、②=h、③=a、④=g、⑤=c、⑥=i、⑦=d、⑧=j」と入り、したがって、正解は肢5となる。

①、②について

①には承継的共同正犯の肯否についてのAの見解の理由が、②には同見解の結論が入る。承継的共同正犯の肯否については、全面的に肯定する見解(Ⅰ説)、限定的に肯定する見解(Ⅱ説)及び全面的に否定する見解(Ⅲ説)が対立している。Bの第1発言から、Aの見解はⅢ説であることが分かる。Ⅲ説は、後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、それが一定の構成要件に該当する限度で共同正犯が成立すると考えることを理由とする。したがって、①には「b. 後行者が因果的影響を与えた行為・結果のみを独立に評価し、それが一定の構成要件に該当する限度で共同正犯が成立する」が、②には「h. 全面的に否定」が入る。

③、④、⑤について

③には承継的共同正犯の肯否についてのBの見解の理由が、④には同見解の結論が入る。④には承継的共同正犯の肯否についてのCの見解の結論も入り、承継的共同正犯の肯否についての結論自体は、BとCとで同じであることが分かる。そして、⑤にはCの見解の理由が入る。③と⑤にはそれぞれ異なるものが入るから、BとCとで異なる理由に基づくことが分かる。Ⅱ説の理由については、後行者が関与する時点において、なお先行者が実現しようとしている結果については因果性を有することが可能であるとする見解(Ⅱ₁説)や、先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべきであるとする見解(Ⅱ₂説)などがある。語句群を見ると、Ⅱ説の理由になり得る語句は、Ⅱ₁説の内容となるaとⅡ₂説の内容となるcしかないから、BとCの各見解は、それぞれⅡ₁説かⅡ₂説のどちらかであることが分かる。Ⅱ₂説に対しては、共謀加担前の結果に対する因果性の欠如を埋め合わせることができないという批判がある。Bの第2発言の第1文からすると、Cの見解はⅡ₂説であることが分かる。そうすると、Bの見解はⅡ₁説であることが分かる。したがって、③には「a. 後行者が関与する時点において、なお先行者が実現しようとしている結果については因果性を有することが可能である」が、④には「g. 限定的に肯定」が、⑤には「c. 先行事実を積極的に利用する場合に限って承継的共同正犯を認めるべき」が入る。

⑥について

⑥には、Cの見解であるⅡ₂説からすると、【事例】の後行者に成立する共同正犯の犯罪が入る。語句群を見ると、そのような語句は、iとjしかなく、これらを見比べると、傷害罪の共同正犯の成立範囲が異なっていることが分かる。Cの見解であるⅡ₂説からすると、【事例】の後行者は、共謀加担前の先行者の暴行により被害者が負傷して抵抗が困難になった状態を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用する意思で、更に暴行を加えているから、承継的共同正犯を認め、後行者に共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪の共同正犯の成立を認めることになる。したがって、⑥には「i. 共謀加担前に生じた傷害結果を含む、生じた結果全てについての傷害罪」が入る。

⑦について

⑦には、Cの見解であるⅡ₂説が承継的共同正犯の成立根拠とする事情、すなわち、先行事実を積極的に利用したという事情に対する判例の評価が入る。最決平24.11.6(百選I81事件)は、「原判決の……認定は、被告人において、被害者らが先行者らの暴行を受けて負傷し、逃亡や抵抗が困

難になっている状態を利用して更に暴行に及んだ趣旨をいうものと解されるが、そのような事実があったとしても、それは、被告人が共謀加担後に更に暴行を行った動機ないし契機にすぎず、共謀加担前の傷害結果について刑事責任を問い得る理由とはいえない」としている。したがって、⑦には「d. 後行者が暴行を行った動機ないし契機にすぎない」が入る。

⑧について

⑧には、Bの見解であるⅡ説からすると、【事例】の後行者に成立する傷害罪の共同正犯の範囲が入る。⑧には⑥とは異なる語句が入り、傷害罪の共同正犯の成立範囲を内容とする語句はほかにjしか残っていないから、⑧にはjが入る。Bが支持する判例（前掲最決平24.11.6）が、「被告人は、共謀加担前に先行者らが既に生じさせていた傷害結果については、被告人の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから、傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく、共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴行によって被害者らの傷害の発生に寄与したことについてのみ、傷害罪の共同正犯としての責任を負うと解するのが相当である。」としていることから、⑧には「j. 共謀加担後の傷害結果の発生に寄与した部分についての傷害罪」が入ることが分かる。